TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Santa Marta D.T.C.H., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022)

RADICACIÓN: 47-001-3333-001-2016-00473-01
ACCIONANTE: GIESEKEN CUELLO & CIA. S EN C
ACCIONADO: DIMAR, DISTRITO DE SANTA MARTA – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, CURADURÍA URBANA DE SANTA MARTA, IROTAMA S.A.S. Y VALOR S.A.
MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
TEMA: INFRACCIÓN DE NORMAS URBANISTICAS

Procede esta Corporación a resolver el **Recurso de apelación** interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de 2 de octubre de 2018, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta negó el amparo de los derechos colectivos.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

a.- Pretensiones:

La Sociedad GIESEKEN CUELLO & CIA. S en C., mediante apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos establecido en el artículo 144 del CPACA y en la Ley 472 de 1998 contra la DIMAR, Distrito de Santa Marta – Secretaría de Planeación del Distrito de Santa Marta, Curaduría Urbana de Santa Marta, IROTAMA S.A.S. Y VALOR S.A., en la que solicitaron las siguientes declaraciones y condenas:

> *"**1.** Se amparen los derechos e intereses colectivos de goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, consagrados en el artículo 3° de la Ley 472 de 1998.*
>
> ***2.** Se declare la nulidad de la Resolución N°. 135 del 4 de mayo de 2011, expedida por la Curaduría Segunda Urbana de Santa Marta y la Resolución 043*

del 20 de febrero de 2014, proferida por la Secretaría de Planeación de Santa Marta, al haber sido expedidas por autoridades carentes de COMPETENCIA y autorizar el uso, goce y construcción sobre playa marítima, atribución exclusiva de la DIMAR de que trata el numeral 3° del artículo 13 del Decreto 1469 de 2010.

***3.** Se ordene la demolición de las obras relativas al proyecto denominado **IROTAMA RESERVADO TORRE I**, por ser violatorio de los mencionados derechos e intereses colectivos y no contar con concesión para usar y gozar del predio, así como tampoco el respectivo permiso de construcción.*

***4.** Se condene a las sociedades **VALOR S.A.** e **IROTAMA S.A.S.** al pago de multa de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la infracción de normas urbanísticas, al haber adelantado proyecto por delante de la línea de la playa marítima de más de 15 pisos, sin los retiros ordenados en el POT Santa Marta y no contar con concesión para usar y gozar del predio, así como también el respectivo permiso de construcción.*

***5.** Se dicte Resolución del predio ocupado de hecho, conforme a las previsiones del artículo 132 del decreto ley 1355 de 1970, con la finalidad de que sean restablecidos".*

b-. Hechos

Para sustentar las pretensiones el accionante expuso lo siguiente:

*"A través de Resolución No. 135 de 4 de mayo de 2011, la Curaduría Segunda Urbana de Santa Marta otorgó una licencia de construcción para un proyecto denominado **IROTAMA RESERVADO TORRE I**, cuya vigencia fue de 24 meses, posteriormente prorrogado hasta el 4 de mayo de 2014, y finalmente revalidada por la Curaduría Segunda de Santa Marta a través de Resolución No. 247 de 25 de junio de 2014.*

*El 28 de noviembre de 2013, la sociedad **GIESEKEN CUELLO & CIA. S. en C.** denunció ante la Dirección General Marítima DIMAR, el proyecto denominado **IROTAMA RESERVADO TORRE I**, ejecutado por las sociedades **GRUPO VALOR S.A.** e **IROTAMA S.A.S.**, por cuanto dicha edificación invadió zona de playa marítima.*

En el trámite de dicha denuncia, la Dirección General Marítima DIMAR, emitió Concepto Técnico de Jurisdicción B.U.P., en el cual se dictaminó que "la totalidad del área que está siendo utilizada para la construcción del edificio proyectado y denominado como "Irotama Reservado", así como el área que encierra los elementos que delimitan la zona de trabajos, se encuentra ubicada sobre terrero que tiene características técnicas correspondientes a zona de la playa marítima, de acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984.

*De igual forma, mediante inspección de litorales surtida 12 de febrero de 2014, por la **DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA (DIMAR)** se puntualizó que "se evidencian trabajos en la construcción del Edificio Irotama Reservado sobre áreas con características de playa marítima".*

*Sin embargo, contraviniendo lo advertido por la mencionada autoridad pública, mediante Resolución 043 del 20 de febrero de 2014, la Secretaría de Planeación de Santa Marta confirió licencia de intervención y ocupación del espacio público a favor de la sociedad **GRUPO VALOR S.A.***

*En vista de lo anterior, el 8 de enero de 2015, la sociedad **GIESEKEN CUELLO & CIA S en C,** a través de apoderado, presentó derecho de petición ante la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta, con el fin de que, entre otros, se certificara sobre las condiciones de edificabilidad del proyecto **IROTAMA RESERVADO TORRE I,** uso del suelo, tratamientos urbanísticos del polígono, la existencia de infraestructura urbanísticas y si en el sector estaba permitido el adosamiento de edificaciones.*

Previa intervención del juez de tutela, la referida Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta mediante acto administrativo identificado con el No. 0626 del 16 de marzo de 2015, citando las normas relativas a POT de Santa Marta, sostuvo que "la normativa del sector dice: (…) Altura permitida: ***15 pisos y establecen a 80 Mts. de la línea de playa.***

No obstante la Resolución No. 135 del 4 de mayo de 2011 de la Curaduría Segunda Urbana de Santa Marta, mediante la cual se concedió licencia de construcción, indicó que el proyecto por el Occidente se encuentra a una distancia de "71.04 M con línea recta playa frente al mar caribe" es decir, la edificación de más de 15 pisos no se encuentra a la distancia de 8º Mts. que ordena el POT de Santa Marta.

Como consecuencia, las referidas personas jurídicas, continúan la ejecución del proyecto ***IROTAMA RESERVADO TORRE I****, edificando dicha obra en espacio denominado playa marítima, conculcando los derechos e intereses colectivos de goce de espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, así como también transgrediendo la normativa urbana que rige en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.*

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 3 de junio de 2016, se radicaron memoriales ante las accionadas, con el fin de solicitar la adopción de medidas tendientes a la protección de los derechos e intereses colectivos.

Mediante decisión administrativa del 21 de junio de 2016, la DIMAR, contestó indicando que no era la entidad competente para tomar las medidas necesarias para garantizar el goce de los derechos e intereses colectivos reseñados, por cuanto dichas atribuciones le corresponden a la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

A través de oficio 0605 de 21 de junio de 2016, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, respondió indicando que dirigieron el oficio al Capitán de Fragata, Juan Manuel Plaza, solicitando información de los hechos puestos en conocimiento.

Por medio de oficio1156 de 20 de junio de 2016, la Secretaría de Planeación de Santa Marta, adujo que realizarán visita técnica al lugar, con el fin de constatar los hechos narrados en la misiva en comento.

A la fecha, las demás entidades se han mostrado reacias a contestar dicho requerimiento. De igual forma, las respuestas emitidas por las mencionadas autoridades, no comportan garantía a los Derechos e Intereses colectivos de mis mandantes, dado que plantean una visita y la emisión de un oficio, sin que real y materialmente se haya visto reflejado un avance significativo.

Por el contrario, la obra continúa su rumbo, se siguen transgrediendo las normativas constitucionales y legales, así como también violando los precedentes jurisprudenciales y de contera conculcando los derechos e intereses colectivos de mi prohijado, lo cual, por sí solo, los legitima para impetrar la presente demanda, habiéndose superado el requisito de procedibilidad contemplado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

C- Contestación de la demanda.

IROTAMA S.A.S.[1]

[1] Folios 228 - 247

Por medio de apoderado judicial la sociedad IROTAMA S.A.S., en primer lugar se opuso a las pretensiones de la demanda, puesto que a su juicio la misma no persigue el interés general, sino que se erige bajo razones individuales, por cuanto al actor se le está violando una servidumbre de vista, a todas luces ilegal sobre predio privado, con motivo de la construcción legítima del proyecto en cuestión *"Irotama Reservado Torre I"*.

Por otro lado, señaló que el demandante ha ejercido acciones judiciales previas con el fin de evitar la construcción del proyecto, la cual se ajusta a las normas urbanísticas distritales; en la presente acción alegó una supuesta ocupación del espacio público.

Respecto de las pretensiones, se opuso a cada una de ellas manifestando que, no se han violado derechos e intereses colectivos de goce de espacio público y por tanto, no existe vulneración al patrimonio público; esbozó que la acción popular no puede utilizarse para decretar la demolición de un bien construido en propiedad privada; el mecanismo empleado no es idóneo para pretender la nulidad de actos administrativos otorgados en debida forma, por último es improcedente condena por violación a normas urbanísticas debido a que todas se hallan ajustadas al procedimiento administrativo nacional y a las normas urbanísticas del distrito.

El demandado formuló las siguientes excepciones:
1- Desconocimiento del actor popular respecto de las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación de espacio público.
2- Desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de construcción.

GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S.A. [2]

Se opuso en forma general a todas y cada una de las pretensiones de la parte accionante por carecer de fundamentos jurídicos y fácticos que permitan su prosperidad. Los hechos de la demanda no tienen relación con las pretensiones y por tanto, no sirven de fundamento fáctico bajo el presupuesto del artículo 52 de la Ley 472 de 1998 en concordancia con el artículo 162 del Código de Procedimiento

[2] Folios: 248 – 279

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 206 del Código General del Proceso. Propuso las siguientes excepciones:

1- Carencia de objeto para demandar.
2- No corresponder los fundamentos y hechos esgrimidos en la demanda a la acción promovida.
3- Desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación de espacio público.
4- Desconocimiento del acto popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de construcción.
5- Genérica.

CURADURÍA URBANA NO. 2. [3]

Se opuso de manera absoluta a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por carecer de causa eficiente y de respaldo fáctico y probatorio. Argumentó que la acción pública es improcedente y no existe vulneración a derecho colectivo.

Indebida escogencia del medio de control

Expresó que lo pretendido por el demandante más allá de una declaración por vulneración de derechos colectivos, tendrá un impacto en situaciones jurídicas particulares, si bien no es el objeto central de la litis es claro que el bien frente al cual se impetra la acción pública se encuentra cobijado por actos administrativos con carácter particular, concreto y en firme, tales como, las licencias de construcción otorgadas por los distintos curadores y la licencia de ocupación e intervención de espacio público otorgada por la Secretaría de Planeación. Adujo en su respuesta que el Honorable Consejo de Estado ha manifestado que para que proceda acciones populares contra los actos administrativos se requiere que se demuestre que el acto administrativo es la fuente o amenaza de los derechos colectivos invocados.

Además de la anterior propuso las excepciones de: Pleito pendiente entre las partes, irretroactividad de la ley 472 de 1998, inexistencia de vulneración contra el derecho

[3] Folios 280 - 301

colectivo de goce del espacio público, falta de obligatoriedad de los fundamentos jurídicos y técnicos aducidos por el demandante, insuficiencia probatoria.

Por último, solicitó que se declararán probadas las excepciones propuestas, la improcedencia de la acción popular y la absolución de la Curaduría Urbana No.2.

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA[4].

Mediante apoderado judicial presentó entre otras la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta el artículo 14 de la Ley 472 de 1998, precisando que la Dirección General Marítima es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, del orden nacional, que corresponde ejecutar la política de gobierno en materia marítima y que la misma no está facultada para llevar a cabo la restitución material de los bienes de uso público que se encuentren ocupados de manera ilegal según el artículo 132 del Código Nacional de Policía, dicha competencia radica en los alcaldes en cada uno de sus municipios.

Aseveró que es cierto que la capitanía de Puerto de Santa Marta mediante concepto técnico No. 001-CP04-ALITMA-613 del 14 de enero del 2014 se determinó que el área objeto de inspección es una Costa baja de material no consolidado característico de playa marítima con predominio de un tamaño predominante lo que indica que posiblemente el sedimento tenga más de un origen. La marea que se presenta en el Caribe y la medición de la línea de más alta marea determinando en el proyecto realizado por el CIOH se obtiene el área de interés se encuentra a una distancia mínima y aproximada de 51 metros promedio y para la línea de más baja marea se presenta una distancia mínima de 60 metros en promedio.

Por tanto se concluye que la totalidad del área que está siendo utilizada para la construcción del edificio denominado Irotama Reservado, así como el área que encierra los elementos que delimitan las zonas de trabajo, se encuentra ubicada sobre un terreno que tiene características técnicas correspondientes a zona de playa marítima de acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto ley 2324 de 1984.

---

[4] Folios 316- 342

Se evidencia que la Dirección General Marítima - DIMAR en uso de sus facultades ha realizado gestiones tendientes a determinar si existe responsabilidad por parte de las constructoras para iniciar un procedimiento sancionatorio. Así mismo reiteró que en cumplimiento de sus funciones y parámetros legales ha iniciado evaluado el terreno donde se está construyendo el proyecto con el fin de determinar si hace parte bien de uso público llegando a la conclusión por medio del citado consejo técnico que el terreno tiene característica de playa marítima, así las cosas, se existe falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no radica en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General marítima capitanía de Puerto, la facultad legal para regular y ejecutar las acciones necesarias para recuperar materialmente las áreas de playas marítimas ocupadas ilegalmente en armonía con el decreto 2324 ibídem.

En relación a las pretensiones argumentó que no ha vulnerado ninguno de los derechos colectivos reclamados, recordó que la autoridad marítima ejerce las funciones atribuibles sobre los bienes de uso público bajo jurisdicción establecido en el artículo 5 del Decreto ley 2324 de 1984; corresponde a la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, como primera autoridad de policía el deber jurídico de ordenar la vigilancia y protección del espacio público así como adelantar el proceso político para la restitución física de los bienes de uso público con fundamento en lo expuesto en el artículo 9 de la ley 472 de 1998. Por último, solicitó la desvinculación de la presente acción popular.

DISTRITO DE SANTA MARTA [5]

Por su parte, el Distrito de Santa Marta frente a los hechos del libelo demandatorio refirió que a raíz de los mismos el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en este caso no está llamado a prosperar, por cuanto no puede desvirtuar la legalidad de los actos administrativos en comento trayendo a colación lo preceptuado en el inciso 2 del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, por tanto se está pretendiendo darle un trámite diferente al que corresponde para atacar los actos administrativos.

Reiteró el Distrito que el legislador le prohibió al juez popular anular actos y contratos usando el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos de acuerdo con el artículo precitado.

---

[5] Folio 343 – 353

Se opuso a todas las pretensiones por carecer de fundamento fáctico o jurídico y a su turno presentó las siguientes excepciones:

1- Improcedencia de este medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, por perseguirse el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.
2- Carencia total del objeto del medio de control popular en tratándose de actos administrativos.
3- Falta de legitimación en la causa por pasiva del alcalde distrital.

Indicó que en el hipotético caso de probarse alguna violación o amenaza de los derechos e intereses colectivos debería llamar a responder a la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación Distrital únicamente. Así mismo mencionó que de los beneficiados con los actos administrativos es el grupo Irotama S.A.S., teniendo en cuenta el principio *"Ubi emolumentum ibi Onus ese debet",* luego se encuentra probada la falta de legitimación por pasiva del Alcalde Distrital.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta D.T.C.H., declaró probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción, propuesta por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta, e improcedencia de este medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, por perseguir el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos y carencia total del objeto del medio de control popular en tratándose de actos administrativos propuesta por el Distrito de Santa Marta, en relación con las pretensiones de que se declaren nulas las resoluciones 135 del 4 de mayo de 2011, expedida por la Curaduría Urbana No. 2, y 043 de 20 de febrero de 2014, proferida por la Secretaría de Planeación del Distrito de Santa Marta.

Así mismo, declaró no probada la excepción de pleito pendiente e irretroactividad de la Ley 472 de 1998, propuesta por la Curaduría Urbana No. 2.

Declaró probadas las excepciones de Desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación de espacio público y desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de construcción, propuestas por

Irotama S.A.S., también las excepciones de No corresponder los fundamentos y hechos esgrimidos en la demanda a la acción promovida, desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación de espacio público y desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de construcción propuestas por Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A., además las excepciones de inexistencia de vulneración contra el derecho colectivo al espacio público, falta de obligatoriedad de los fundamentos jurídicos y técnicos aducidos por el demandante e insuficiencia probatoria – Carga probatoria en cabeza del accionante propuestas por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta.

Por último, negó el amparo de los derechos colectivos a la utilización y defensa de los bienes de uso público y goce del espacio público y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes de Santa Marta.

II. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación[6] contra la sentencia de primera instancia proferida el 2 de octubre de 2018, por el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta D.T.C.H., indicando en resumen lo siguiente:

Aseveró que el principal insumo probatorio de la sentencia fue la Carta Catastral, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sin embargo aduce que es impertinente para establecer la distancia entre la línea de paramento del edificio hasta la línea de playa marítima de acuerdo con el artículo 37 de la Resolución 0070 del 2011[7].

La Carta Catastral allegada al expediente es la demarcación de un terreno, pero no se ilustra la estructura que se levanta sobre el globo de terreno, que es lo que realmente a juicio del apelante es importante demostrar en el proceso. Señaló que el documento en comento refleja un plano en el que se muestra que el edificio no sobrepasa una línea; pero ello no quiere decir que materialmente no esté ocurriendo lo contrario.

---

[6] Folios 732 - 745
[7] Resolución 0070 del 2011, ARTÍCULO 37.- Carta catastral urbana.- Es el documento cartográfico georreferenciado en el que se encuentran individualizados los predios que conforman la manzana catastral con su respectiva identificación y nomenclatura vial y domiciliaria.

Manifestó que por sugerencia del experto que acudió al proceso de la referencia, la forma de definir la litis era efectuando las mediciones con los equipos idóneos y con el personal requerido; sin embargo, el Despacho mediante auto de 12 de julio de 2018 se ciñó a la carta catastral urbana del IGAC, que venía siendo mencionada por la Sociedad Irotama S.A.S.

Reconoció que el argumento para descartar la prueba pericial fue que esta no se había realizado en oportunidad probatoria, y es cierto, toda vez que junto con la demanda se había presentado dos dictámenes expedidos por la DIMAR, donde se concluyó que se usurparon bienes de la nación. Afirmó que no resulta de recibo que se diga que la determinación de si la obra se adelantaba en playa o no *"debía dilucidarse en el curso del proceso"* pues, si se dilucido con los dictámenes de la DIMAR.

El apelante reiteró en su escrito los conceptos de la DIMAR recalcando su idoneidad para desatar la litis, no es lógico a juicio del demandante que no se le haya dado valor probatorio y que en su lugar, se prefirió la carta catastral urbana.

En conclusión en el caso de la referencia según los argumentos expresados por este extremo ha existido una indebida valoración probatoria, a su vez el a – quo no analizó si el proyecto IROTAMA RESERADO TORRE I, violaba o no las normativas urbanísticas de la ciudad y del sector donde se encuentra construido.

Esgrimió que el proyecto no respetó la distancia de la playa de cara al mar caribe, es decir 80 metros de la línea de la playa, y que por mandato legal debieron observarse según el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta para la edificación de más de 15 pisos, igualmente que la Secretaría de Planeación del Distrito a la hora de expedir la licencia de intervención de espacio público en favor de la Sociedad Valor S.A., debió contar con la concepto favorable de la DIMAR – Artículo 13 del Decreto 1469 de 2010.

En conclusión, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia en su integridad, puesto que está viciada de valoración probatoria, debido a que se soslayaron elementos de juicio que determinan que el Proyecto IROTAMA RESERVADO TORRE I, transgrede bienes de uso público, para en su lugar brindar mérito probatorio a la carta catastral que por mandato legal no tiene fuerza para definir si el inmueble se haya construido en zona de playa marítima, y por tanto se peticionó el amparo de los derechos e intereses colectivos invocados en la acción

popular consagrados en literal d) (*el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público*) ;y m) (*la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes*) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

IV. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA.

Mediante auto[8] del 27 de noviembre de 2018, este Despacho admitió el recurso de apelación presentado por la parte accionada, en contra de la sentencia de 2 de octubre de 2018, dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta.

Por auto[9] de 17 de enero de 2019 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión.

- **Parte demandante:** El apoderado de esta parte demandada presentó sus alegatos[10], reiterando en lo sustancial los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

- **Parte demandada:**

CURADURÍA URBANA No. 2 [11]

Mediante apoderado judicial la curaduría urbana alegó en suma lo siguiente:

En su escrito reiteró que las actuaciones adelantadas por la Curaduría se encuentran bajo observancia de las disposiciones legales para el otorgamiento de licencias de construcción de modalidad de obra nueva sobre el predio que se pretende alegar la calidad de bien de uso público y que no se ha vulnerado derecho colectivo alguno, cosa que no ha sido capaz de demostrar el actor.

Aunado a lo anterior, recordó la falta de fortaleza probatoria del accionante, recordó que la DIMAR no tiene facultades absolutas en su tarea de delimitación. El concepto técnico no es obligatorio ni concluyente.

---

[8] Folio 754
[9] Folio 760
[10] Folio 800 – 811.
[11] Folio 763 - 766

Subrayó además, que los conceptos técnicos emitidos por la DIRECCIÓN GENERAL marítima no poseen efectos jurídicos generales y por definición son criterios orientadores para el particular caso.

Expuso concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 2 de noviembre de 2005, en donde se consideró que *"la DIMAR no ha recibido de la ley facultad para delimitar las playas y terrenos de bajamar del país mediante acto administrativo que tenga un efecto vinculante de carácter general".* El demandante fundamentó sus pretensiones en el concepto técnico el cual carece de capacidad de generar efectos jurídicos, no puede decidir que es playa o que no es playa, es un insumo para tomar una decisión dentro de una investigación con fines sancionatorios. Por tanto, solicitaron que se declare la no existencia de violación de derechos colectivos a su representada.

IROTAMA S.A.S.[12]

Manifestó en esta oportunidad el apoderado judicial de la accionada, que resulta imposible a través del medio utilizado pretender la anulación de actos administrativos en firme; y es lo que llevó a la prosperidad de las excepciones presentadas en favor de su mandante. Por otra parte, la ley 1437 de 2011, excluyó la anulación de actos administrativos dentro del medio de control de la referencia, sin embargo, facultó al A- quo para tomar medidas en contra de amenaza o vulneración de los derechos colectivos.

En inspección judicial el día 24 de octubre de 2017, se comprobó que no existe adosamiento entre los edificios, se demuestra que el interés del demandante es particular y no colectivo; de acuerdo con la carta catastral el inmueble se encuentra dentro de los límites descritos por el IGAC, por lo cual no existe invasión a zona de playa marítima; se obtuvieron las licencias y permisos necesarios para la construcción del proyecto de conformidad con el POT y demás normas.

En conclusión, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.

GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S.A. [13]

---

[12] Folios 788-789
[13] Folios 790- 795.

Por su parte, esta sociedad alegó que no se probaron los fundamentos fácticos y jurídicos. Está comprobado que dentro del medio de control no se puede fallar como si se tratara de una acción de nulidad, que la DIMAR conceptúo que los predios de IROTAMA no corresponden a su jurisdicción y que la licencia de construcción, sus prorrogas y su revalidación a la fecha no han sido declaradas nulas por tanto gozan de presunción de legalidad. Recalcó que tres curadores urbanos revisaron el proyecto y expidieron las resoluciones por encontrarlas ajustadas a derecho.

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA[14]

La apoderada de la parte manifestó que de acuerdo con los conceptos expuestos por la sala de consulta y servicio Civil del Consejo de Estado de 29 de abril de 2014, la Dirección General Marítima, podrá elaborar mapas para la delimitación geográfica de las playas y los terrenos de bajamar, dicha delimitación solamente es obligatoria o vinculante para los propios funcionarios y empleados de dicha autoridad así como para las personas que se encuentran directamente interesada o que resulten afectadas por las actuaciones que realice DIMAR en ejercicio de sus funciones de conformidad con el decreto ley 23 24 de 1984 y la ley 1450 de 2011 y según lo expuesto en el concepto número 1682 de 2 de noviembre 2005, emitido por la misma sala.

Así las cosas, dichos conceptos sólo podrán ser tenidos en cuenta dentro de las investigaciones administrativas por ocupación indebida del espacio público propias de la competencia de la Dirección General Marítima, por lo tanto, tales conceptos carecen de valor probatorio en investigaciones distintas llevadas por la autoridad marítima. Indicó además que en la inspección judicial realizada dentro del proceso no fue posible determinar si la torre 1 del edificio Irotama Reservado se encontraba invadiendo zonas de playa marítima, dado que , en dicho dictamen pericial no se contempló la utilización de instrumentos topográficos idóneos para la realización práctica de la distancia existente entre la edificación y la línea de la playa; con el objetivo de suplir la deficiencia probatoria el Despacho oficio al instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que a través de documento oficial permitirá especificar si el edificio construido en el lote 01 42 de la manzana 62 del sector bien ubicado en las

[14] Folios 797-799

coordenadas geográficas 11° 13' 10.71´´, se encontraban o no dentro de los límites establecidos por el Instituto en la carta catastral.

Consideró que había que tomar en cuenta que la carta catastral es el documento que permite consultar el aspecto físico, jurídico y económico de un inmueble de acuerdo con la información almacenada en la base de datos del IGAC, determinada por expertos en el tema topográfico esta adquiere especial consideración para constituir, modificar o transmitir derechos reales, así como para relacionar los bienes inmuebles en cabeza de una persona.

Esbozó también que en esta carta se pudo constatar que la torre 1 del proyecto Irotama Reservado no se encuentra excediendo la línea de parámetros establecida para el predio sobre la cual está construida, por tanto, queda evidenciado que no existe invasión del espacio público específicamente playa marítima. El proyecto se sitúa sobre predio de propiedad privada, nos permite concluir entonces que es clara la validez del proyecto de construcción puesto que el documento otorgado por el IGAC tiene valor probatorio suficiente para demostrarlo, haciendo innecesaria cualquier práctica y decreto de pruebas judiciales adicionales.

Para finalizar reseñó que si bien es cierto que el área utilizada para la construcción del edificio Irotama Reservado Torre 1 al igual que el área que encierra los elementos tendientes a delimitar la zona de trabajos se encuentra ubicada sobre terrenos que parece tener características técnicas correspondientes a zona de playas marítimas, también es cierto de que existe la matrícula inmobiliaria número 080-83688 inscrita en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos que demuestra la titularidad del predio objeto de investigación por lo cual solicitó la confirmación de la sentencia de 2 de octubre del 2018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo.

DISTRITO DE SANTA MARTA: Reiteró en lo sustancial lo manifestado en la contestación.

MINISTERIO PÚBLICO – CONCEPTO.

En síntesis el delegado del Ministerio Público manifestó lo siguiente[15].

> *"El Ministerio Público solicita al Honorable Tribunal Administrativo del Magdalena, que se revoque la sentencia apelada en cuanto declaró probadas las excepciones que denominó indebida escogencia de la acción, inexistencia de vulneración de*

[15] Folio 813 - 830

derechos colectivos al espacio público e insuficiencia probatoria, improcedencia del medio de control por perseguir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, desconocimiento del actor popular de las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación del espacio público y licencias de construcción.

Respetuosamente se solicita se esclarezcan los puntos obscuros señalados en este concepto de que se haga uso de la facultad de decretar pruebas de oficio, tal como lo señala la Corte Constitucional en sentencia T- 429 de 2013.

En el evento que no se llegare a considerar necesaria la práctica de las pruebas aquí señalada, se solicita al Tribunal Administrativo del Magdalena se nieguen las súplicas de la demanda pero por falta de pruebas de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados; sin embargo, en este evento se solicita se conmine a la DIMAR para que dentro de un plazo razonable proceda a adoptar las decisiones de fondo en el trámite administrativo iniciado con fundamento en el concepto técnico de jurisdicción número 001-CP04-ALITMA-613 del 14 de enero de 2014, previa práctica de estudio técnico por parte del CIOH que incluya la realización de estudios de suelo, granulométricos, topográficos, botánicos, agrologicos, hidrográficos, hidrológicos y la utilización del sistema lidar, para que de esta manera se pueda determinar la presencia o no de material consolidado, la línea de vegetación permanente, el marcado cambio geomorfológico y la determinación de la menor y más alta marea en el sector, criterios relevantes para determinar si se está en presencia de playa marítima y hasta dónde llega la misma; de igual manera, que se proceda por parte de la Secretaría de Planeación Distrital a adelantar la actuación administrativa correspondiente a efectos de establecer si se ha incurrido en infracciones urbanísticas a la luz del artículo 103 de la Ley 388 de 1997, en desarrollo del proyecto IROTAMA RESERVADO TORRE I".

V. CONSIDERACIONES

5.1.- Competencia para conocer del recurso de apelación.

El artículo 16 de la Ley 472 de 1998 en armonía con el artículo 153 del C.P.A.C.A, este último dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Jueces Administrativos.

El recurso que se resuelve en la presente providencia corresponde a la apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta dentro de la acción de la referencia, por tanto, es competente esta Corporación para conocer la misma.

5.2.- Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si se debe confirmar o no la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual habrá que determinarse:

Si existe vulneración u amenaza de los derechos e intereses colectivos de goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, contenidos en los literales d) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, por parte de: Irotama S.A.S., Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A, el Distrito de Santa Marta – la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Dirección General Marítima y Curaduría Urbana Nº 2 de Santa Marta.

Si es viable por este medio de control declarar la nulidad de los actos administrativos - Resolución No. 135 de 4 de mayo de 2011, expedida por la Curaduría Urbana 2 de Santa Marta y la Resolución No. 043 de 20 de febrero de 2014, expedida por la Secretaría de Planeación de Santa Marta.

También se deberá verificar si se debe revocar la sentencia en lo que respecta a las órdenes de declarar probadas las excepciones de merito propuestas por la parte demandada, para lo cual se debe establecer si constituyen excepciones o argumentos de fondo.

5.3. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos Ley 1437 de 2011.

"ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. *Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.*

Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos".

5.4. Derechos e intereses colectivos invocados en el sublite – Ley 472 de 1998.

"ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. *Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:*

(…) ***d)*** *El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;*
m) *La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; (…)"*

Del literal d) goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

Respecto de la naturaleza, características y condiciones para la ocupación de los bienes de uso público, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera - Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS., en providencia del 18 de mayo de 2017, radicación: 13001-23-31-000-2011-00315-01, precisó:

> *"6.3.1. La utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce del espacio público. En relación con la categoría de los bienes de uso público, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado la clasificación legal de los bienes de dominio del Estado, con fundamento en la distinción entre bienes de uso público y bienes fiscales, definidos ellos en los términos del artículo 674 del Código Civil.*
>
> *En ese contexto, se tiene, que si bien al artículo 674 del C.C., distinguió entre bienes fiscales y bienes de uso público, no consagró ninguna definición respecto de lo que debe entenderse por uno u otro, razón por la cual del desarrollo de estas nociones se han ocupado tanto la jurisprudencia como la doctrina. Sin embargo, de las normas del Código Civil sí se deriva una primigenia clasificación –que hoy en día ha sido ampliada a través de diferentes disposiciones–:*
>
> *i). Bienes fiscales propiamente dichos, que se gobernaban por el Código Fiscal y el Código de Régimen Político y Municipal y en lo no previsto por ellos por la legislación común; ii) Bienes fiscales adjudicables como las minas y los baldíos; iii) Bienes de uso público, que se gobernaban por las reglas del derecho público, son aquellos que se caracterizan por pertenecer al Estado u otra entidad de derecho público, estar destinados al uso común de los habitantes y encontrarse por fuera del comercio, es decir, se reputan –de conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política- como bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables3 . Vale decir, que entre este tipo de bienes se incluían, además, los denominados baldíos reservados de la Nación (como las islas y costas) considerados inadjudicables y, de hecho, el artículo 166 del Decreto 2324 de 1984 establece que "[l]as playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso o goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni el subsuelo" (negrilla fuera de texto).*
>
> *Sobre la naturaleza, las características de los bienes de uso público y las condiciones para su ocupación, la Corte Constitucional4 se ha pronunciado de la siguiente manera:*

> *"[…] cabe advertir que la vocación de los bienes de uso público es su utilización y disfrute colectivo en forma libre, sin perjuicio de las restricciones que en beneficio del grupo social mismo, puedan ser impuestas por parte de las autoridades competentes, de ahí su carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables que les otorga el artículo 63 de la Carta. Con todo,* ***no resulta contrario a la Constitución que sobre los bienes de uso público se permita un uso especial o diferente, por parte de la Administración, a través del otorgamiento de concesiones o permisos de ocupación temporal, sin que por ello se transmute el carácter de público de esa clase de bienes. Es decir, que el otorgamiento de esa concesión o permiso para un uso especial en bienes de uso público por parte de los particulares, no implica la conformación de derechos subjetivos respecto de ellos, por cuanto la situación que se deriva del permiso o de la concesión es precaria, en el sentido de que son esencialmente temporales y por lo tanto revocables o rescindibles en cualquier momento por razones de interés general. En ese orden de ideas se tiene que cuando bienes de uso público de la Nación, sean puestos en manos de particulares, no puede ser por "cualquier razón",*** *como lo contempla el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 768 de 2002, sino únicamente en virtud de autorización de autoridad competente en la forma establecida en la ley. En efecto, el Decreto 2811 de 1974 o Código de Recursos Naturales, establece los "modos de adquirir derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio público", esto es a través de permisos y concesiones temporales, como se dispone en el Título V del citado Decreto. Por otra parte, el Decreto 2324 de 1984, establece en el artículo 169 que la Dirección General Marítima y Portuaria podrá otorgar concesiones para uso y goce de las playas marítimas y de los terrenos de bajamar, previo el cumplimiento de los requisitos que señala esa norma. Así mismo, el artículo 175 consagra dentro de los requisitos exigidos para autorizar el permiso, que al vencimiento del término para el cual se concede, se "reviertan a la Nación las construcciones" y, se obliga al interesado a comprometerse a "reconocer que el permiso no afecta el derecho de dominio de la Nación sobre los terrenos, ni limita en ningún caso el derecho de ésta para levantar sus construcciones en cualquier sitio que considere conveniente (Negrita y subrayado fuera de texto)".*

Respecto de la procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, en sentencia del 10 de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 17001-23-31-000-2011-00424-03(AP), manifestó:

> *"114. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este derecho implica "[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo […]*
>
> *115. De igual forma, esta sección mediante sentencia de 7 de abril de 2011 , determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad105; ii) protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio106; y iv) Atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional*

en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible (subrayado fuera de texto)

116. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones político - administrativas - de organización física- contenidas en los mismos108. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros.

117. Así las cosas, para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

118. En efecto, esa sección110 ha manifestado al respecto que:

"[…] el derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir […]".

119. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo de la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes implica que las autoridades públicas y/o los particulares desconozcan la normativa en materia urbanística y usos del suelo.

120. ***Corporación establece que, para que el mismo se entienda vulnerado o amenazado no basta infringir las normas urbanísticas, sino que se requiere demostrar el daño o la amenaza de daño al interés general".***

5.5. Naturaleza y fin de las acciones populares.

En Sentencia[16] de Unificación el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero William Hernández Gómez, el 13 de febrero de 2018, recordó la naturaleza y fin de estas acciones constitucionales en los siguientes términos.

---

[16] CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU) Actor: ANTONIO JOSÉ RENGIFO Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PORTUARIA DE COLOMBIA (DIMAR) Y OTROS.

"25. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (ver art. 2.º de la L. 472) y los principales elementos definitorios de su naturaleza jurídica se resumen así:

a) Es una expresión concreta el derecho de acción. *Es decir, le permite a los titulares solicitar ante el juez competente que mediante orden judicial, provea tutela judicial efectiva de los derechos e intereses colectivos vulnerados o cese la amenaza de ello.*

b) Es principal: *La acción popular es de carácter principal y en consecuencia autónoma, lo cual implica que no depende de la inexistencia de otras acciones para solicitar la protección del derecho o interés invocado. Muy diferente, por ejemplo, a la acción de tutela, que es eminentemente residual.*

c) Es preventiva: *Porque procede, incluso, cuando el derecho o interés colectivo no ha sido vulnerado si se concluye que está amenazado y que es necesario evitar un daño contingente o hacer cesar el peligro. Lo anterior, pese a que las acciones u omisiones sean remotas, ya que lo determinante es que sus efectos persistan frente a la amenaza o puesta en peligro.*

d) Es eventualmente restitutiva: *Porque el juez de la acción popular puede ordenar que las cosas vuelvan al estado anterior cuando fuere posible.*

e) Es actual, no pretérita. *Ello significa que habrá carencia de objeto si ha cesado la vulneración o amenaza del derecho colectivo. Por el contrario, procederá este mecanismo de protección -aunque el hecho generador sea anterior y se haya consumado-, si la violación, amenaza o puesta en peligro del derecho o interés colectivo, persiste, sea actual o inminente, o imprescriptible, inalienable, como ocurre con la conservación del patrimonio cultural.*

f) La vulneración o amenaza debe ser real, inminente, concreta. *Tal como lo ha precisado el Consejo de Estado la amenaza y vulneración denunciadas, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo.*

g) Es excepcionalmente indemnizatoria. *Es decir, en aquellos casos en los cuales se ha probado el daño a un derecho o interés colectivo, el juez podrá condenar al pago de perjuicios en favor de la entidad pública no culpable, que tenga entre sus funciones la vigilancia o protección del derecho o interés colectivo vulnerado (artículo 34 de la L 472).*

h) La prueba de la vulneración o amenaza está a cargo del actor popular. *Esto implica, en principio, que la carga de la prueba la tiene el demandante; sin embargo, si por razones de orden económico o técnico este no pudiere asumirla, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, en la que deben quedar plenamente demostradas las acciones u omisiones denunciadas o queden evidenciadas.*

26. Así mismo, de acuerdo con estas características, el juez de la acción popular decide el asunto, entre otros, bajo los siguientes parámetros:

a) *Tiene en cuenta los principios consagrados en normas constitucionales, convencionales, o legales, que expresan valores superiores, o bien, como norma programática o directriz, que orienta la función pública y la administrativa.*

b) *Constata la efectiva vulneración o agravio, o el daño contingente, o la amenaza de uno o varios derechos e intereses colectivos invocados o que, de oficio, encuentre vulnerados o en riesgo.*

c) *Identifica la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, causante de la violación o amenaza81.*

> ***d)*** *Definidos los supuestos fácticos y jurídicos, en la sentencia se ordenan las medidas pertinentes, oportunas y procedentes conforme a lo indicado en el artículo 34 de la Ley 472".*

5.6. Anulación de actos administrativos vía acción popular - IMPROCEDENCIA

En la sentencia de unificación precitada se sentó postura sobre la imposibilidad del juez constitucional para eventualmente declarar la nulidad de los actos administrativos bajo los siguientes criterios:

> ***"a) Primer criterio de unificación: Acción popular y nulidad de actos administrativos.***
>
> *30. Las tesis que se adoptará respecto de este criterio consiste en que el juez de la acción popular no puede declarar la nulidad de los actos administrativos causantes de la amenaza o violación de derechos e intereses colectivos, aún si se trata de hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 1437.*
>
> *56. Conforme a lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unifica el criterio interpretativo así:* ***En las acciones populares el juez no tiene la facultad de anular los actos administrativos, pero sí podrá adoptar las medidas materiales que salvaguarden el derecho o interés colectivo afectado con el acto administrativo que sea la causa de la amenaza, vulneración o el agravio de derechos e intereses colectivos;*** *para el efecto, tendrá múltiples alternativas al momento de proferir órdenes de hacer o no hacer que considere pertinentes, de conformidad con el caso concreto (subrayado y negrita fuera de texto)".*

Así las cosas, está claro que bajo ninguna circunstancia el juez constitucional podrá declarar la nulidad de los actos administrativos, simplemente bajo su poder hará cesar la causa o vulneración que esté generando agravios o amenace los derechos o intereses colectivos.

5.7. Carga de la prueba en materia de acciones populares

El artículo 30 de la Ley 472 de 1998, estipula la carga de la prueba en el actor popular así:

> *"**ARTICULO 30. CARGA DE LA PRUEBA.** La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella.*
>
> *En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos".*

El Honorable Consejo de Estado – Sección Primera, en Sentencia[17] de 30 de junio de 2011, reiteró que la carga de la prueba corresponde al actor con el fin de demostrar los supuestos de hecho que sustentan la invocación del medio de control:

> *"Se entiende que le corresponde al actor probar los hechos, acciones u omisiones que a su juicio constituyen la causa de la amenaza o la vulneración de los derechos e intereses colectivos cuya protección se pretende con la acción. Es evidente que no basta con indicar que determinados hechos violan los derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o vulneración; el demandante tiene la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones. Sobre la carga de la prueba en acciones populares, esta Corporación ha señalado que:*
>
> *"...la Sala considera importante anotar, que la acción popular no está diseñada para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente ya sea en el ámbito público o privado. Por el contrario, como se indicó al inicio de estas consideraciones,* ***la acción popular tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos, cuando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto la amenaza como la vulneración, según el caso, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por el actor popular, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, tiene la carga de la prueba****.*
>
> *"Dado que los actores no demostraron de ninguna manera el supuesto hecho que generaba la violación de los derechos colectivos (...) confirmará la Sala la sentencia proferida por el tribunal de instancia."1 (resaltado fuera de texto)".*

Es menester recordar que lo anterior, no impide al juez popular a emplear sus facultades de decretar pruebas de oficio para constatar si existe o no vulneración de los derechos e intereses colectivos.

5.9. Pruebas

Son pruebas relevantes para decidir de fondo sobre el caso de estudio las siguientes:

- Copia de la Licencia de Construcción No. 043, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta, por solicitud de Irotama S.A. para el Predio No. 011000620001000, con matrícula inmobiliaria No. 080-83688 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, para la construcción de una edificación aparta - hotel, en predios de Irotama S.A. tercera etapa, que consta de

---

[17] Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia de treinta (30) de junio de dos mil once (2011), Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP).

15 pisos con semisótano y primer piso; con 140 parqueos, 150 unidades de aparta-suites de diferentes características repartidos en 8 tipos (folio 467).

- Copia de la Resolución No. 135 de 4 de mayo de 2011, por medio de la cual la Curaduría Urbana No.2 de Santa Marta otorgó licencia de construcción No. 043, en la modalidad de obra nueva, a la Sociedad Irotama S.A., para que lleve a cabo la construcción de una edificación aparta - hotel, en predios de Irotama S.A. tercera etapa dentro del desarrollo de edificaciones en altura del plan maestro Irotama (folios 25-28).

- Copia de la Resolución No. 240 de 27 de agosto de 2012, a través de la cual la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta adicionó los folios 1 y 2 de la parte considerativa de la Resolución No. 135 de 4 de mayo de 2011, de la licencia de construcción 043 de la misma fecha, y de los respectivos planos aprobados, lo siguiente: matrícula inmobiliaria No. 080-104266 de la Oficina de Registro de Instrumento Públicos de Santa Marta (folios 472-473).

- Copia de la Resolución No. 111 de 11 de abril de 2013, por medio de la cual la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta prorrogó hasta el 4 de mayo de 2014 la vigencia de la Resolución No. 135 de 4 de mayo de 2011, que concedió la licencia de construcción No. 043 a la Sociedad Irotama S.A. (folios 31-32).

- Copia de la Resolución aclaratoria No. 398 de 28 de noviembre de 2013 mediante la cual la Curaduría Urbana No.2 de Santa Marta introdujo una aclaración en la Resolución No. 135 de 4 de maya de 2011, así como en la Resolución No. 111 de 11 de abril de 2013, consistente en adicionar al expediente identificado con el radicado 47-001-2-010-00266 la modificación de titularidad que reposa a nombre de la Sociedad Irotama S.A.S., quedando a nombre del Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A. (folios 29-30).

- Copia de la Resolución modificatoria No. 068 de 5 de marzo de 2014, a través de la cual la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta adicionó al expediente identificado con el radicado 47-001-2-010- 00266 la modificación del constructor responsable, del diseñador estructural, y de los distintos profesionales del proyecto (folios 478 - 480).

- Copia de la Licencia de Construcción No. 002, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta, a favor de Valor S.A., para el Predio No. 011000620142000, con matrícula inmobiliaria No. 080- 104266 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, con fundamento en el Acuerdo 005 de 2000 (folios 486 - 487).

- Copia de la Resolución No. 247 de 25 de junio de 2014, a través de la cual la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta revalidó la licencia de construcción No. 043, amparada mediante la Resolución No. 135 de 4 de mayo de 2011, de acuerdo con los planos presentados sobre un predio ubicado en el Kilómetro 14 Vía Ciénaga Conjunto Cerrado Irotama Lote Irotama Reservado - Torre 1, con inscripción catastral No. 011000620142000, Matrícula Inmobiliaria No. 080-104266 (folios 483-485).

- Petición dirigida a la Dirección General Marítima - Capitanía de Puerto de Santa Marta, por los señores: Use Margarita Gieseken De Cuello y Guillermo Cuello Lacano, cuyo objeto era entregarle copia de la petición presentada el 18 de noviembre de 2013 ante la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta (folio 33-38).

- Copia del concepto técnico jurisdicción B.U.P. de 14 de enero de 2014, suscrito por el Suboficial Jefe Orlando Antonio Muñiz Carióla, Responsable Litorales y Áreas Marinas de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en el cual concluyó, a título de concepto, que: *" La totalidad del área que está siendo utilizada para la construcción del edificio proyectado y denominado Irotama Reservado, así como el área que encierra los elementos que delimitan la zona de trabajos, se encuentra ubicada sobre un terreno que tiene características técnicas correspondientes a zona de playa marítima, de acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984. "* (folios 38 - 44).

- Copia de la Resolución No. 043 de 20 de febrero de 2014, por medio de la cual la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta otorgó licencia de intervención y ocupación de espacio público a favor de la sociedad Grupo Valor S.A. Nit. 830114143-6, Irotama Reservado, Ingeniero Carlos Robles, en la calle 2 No. 112-61, sector de Pozos Colorados, la cual contaba con una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en quedó en firme la Resolución No. 043 de 20 de febrero de 2014. (folios 45-50).

- Copia del informe sobre diligencia de inspección técnica realizada por el Técnico y el Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta, al proyecto arquitectónico denominado Irotama Reservado I, dirigido a la Secretaria de Planeación (folios 56-61).

- Oficio No. 1559 de 29 de diciembre de 2010, por medio del cual la Curadora Urbana No. 2 de Santa Marta le informa al Representante Legal del Condominio Costa Bella que, de acuerdo a los planos aportados, la distancia que existe entre el edificio Costa Bella y el que se pretendía construir por parte de Irotama, es aproximadamente de 40 metros, por lo que no le afecta la vista al mar (folio 62).

- Copia del expediente No. 14032014001, correspondiente a la investigación adelantada por la Dirección General Marítima - Capitanía de Puerto de Santa Marta contra Irotama S.A.S., por la presunta ocupación indebida en bien de uso público de la Jurisdicción de DIMAR, en el cual obra la Resolución de 10 de febrero de 2016, por medio de la cual el Capitán de Puerto de Santa Marta declaró no responsable administrativamente a la Sociedad IROTAMA S.A.S., identificada con el Nit. No. 891700612-4, por construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público sometidos a la jurisdicción de la Dirección General Marítima, en la zona conocida Pozos Colorados, sector lagos del Dulcino, Distrito de Santa Marta, dado que, para el 13 de febrero de 2014, la fecha de expedición del auto de formulación de cargos, y del informe de Inspección Nº 411 de Litorales y Áreas Marítimas de la Capitanía de Puerto de Santa Marta: 18 de diciembre de 2013, la Sociedad IROTAMA S.A. no era titular de la Licencia de Construcción número 043, otorgada por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta mediante la Resolución No. 135 de 4 de mayo de 2011, como consta en la Resolución No. 398 de 28 de noviembre de 2013, y se dispuso el archivo la investigación administrativa sancionatoria adelantada contra la Sociedad IROTAMA S.A.S. (folios 63-74).

- Oficio No. 14201601294 de 21 de junio de 2016, por medio del cual la Capitanía de Puerto de Santa Marta, Dirección General Marítima responde la petición de protección a los derechos o intereses colectivos presentada por el apoderado de la Sociedad Gieseken Cuello & CÍA. S. en C. informándole que su petición es improcedente, porque no es función de la Dirección General Marítima - Capitanía de Puerto de Santa Marta otorgar licencias de construcción, la suspensión de obras de construcción, el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta y la restitución de los bienes de uso público de la Nación (folios 80 - 84).

- Certificado de tradición del predio con matrícula inmobiliaria No. 080 - 83688 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, predio de propiedad de Irotama S.A., del cual se abrió la matricula inmobiliaria No. 104266 (folios148-150).

- Copia del Decreto 477 de 25 de septiembre de 1998, por medio del cual el Comité de Planificación y Desarrollo del Distrito de Santa Marta aprobó el plan maestro conjunto cerrado Irotama (folios 151- 155).

- Certificado de existencia y representación legal de Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. (folios 156 -159).

- Certificado de existencia y representación legal de Irotama S.A.S., expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta (folios 189- 196).

- Certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 080-104266 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta (folios197-198).

- Copia de la sentencia de 27 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del trámite de la acción de tutela presentada por Guillermo Cuello Lascano y Gieseken contra la Dirección General Marítima - Dimar (folios 208-217).

- Copia del plano arquitectónico del Plan Maestro Conjunto Cerrado Irotama (folio 226).

- Copia del dictamen pericial de 20 de enero de 1994, aportado con la contestación de la demanda por Irotama S.A.S. y el Grupo Inmobiliario Valor S.A., suscrito por los peritos: Alvaro Duarte Méndez, Julio Vargas Gómez y Carlos Tejeda Vélez (folios 238-247, 271-279).

- Copia del Auto de 14 de marzo de 2017, por medio del cual el Director General Marítimo decretó la nulidad de lo actuado hasta antes del auto de cierre de investigación emitido el 18 de noviembre de 2015, por el Capitán de Puerto de Santa Marta, dentro de la investigación adelantada por la Dirección General Marítima -

Capitanía de Puerto de Santa Marta, contra Irotama S.A.S. por la presunta ocupación indebida en bien de uso público de la Jurisdicción de DIMAR (folios 448-454).

- Planos de localización del predio con matrícula inmobiliaria No. 080- 104266 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, correspondiente al Irotama Reservado Torre I (folios 497- 499).

- Copia de la Escritura Pública No. 1123 de 23 de agosto de 2016, otorgada por la Alianza Fiduciaria S.A., como vocera del Fideicomiso Irotama Reservado, cuyo objeto es la constitución del reglamento de propiedad horizontal del Edificio Irotama Reservado Etapa 1 (folios 523-526).

- Copia de la Carta Catastral Urbana - Cabecera Municipal, del Predio ubicado dentro de las siguientes coordenadas geográficas: Latitud Norte: 11° 13'72'; Longitud Oeste: 75° 4629, 98"; Norte: 1732533.51818 metros y Este: 983892, 40901 metros (folio 570).

- Copia de algunas actuaciones surtidas dentro del proceso radicado No. 47-001-3333-003-2015-00071-00, medio de control nulidad, adelantado por Condominio Costa Bella contra el Distrito de Santa Marta, ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta (folios 581-590).

- Acta de inspección judicial llevada a cabo el 24 de octubre de 2017, en la que están incluidos los testimonios del Geólogo David Fernando Morales Giraldo y del Ingeniero Carlos Andrés Robles Sánchez (folios 648-651).

- Oficio mediante el cual la parte demandada puso en conocimiento del Despacho que mediante Resolución N° 0134 de 2021, emitida por la DIMAR, se ordenó el archivo de la investigación adelantada por dicha entidad en contra del GRUPO VALOR INMOBILIARIO Y OTROS, con relación la construcción indebida o no autorizadas en bienes de uso público. Situación que fue corroborada por el apoderado de la parte demandante, quien además aclaró que apeló la decisión y a la fecha no se ha decidido el recurso interpuesto.

- Oficio mediante el cual la DIMAR manifestó que los puntos geográficos tomados en campo coincidían con la delimitación predial de los Edificios IROTAMA

RESERVADO y CONDOMINIO COSTA BELLA en la base de datos catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.

5.10. Caso concreto

La Sociedad GIESEKEN CUELLO & CIA S. EN. C., por medio de apoderado judicial interpuso el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, por violación derechos e intereses colectivos de goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, contenidos en los literales d) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, por parte de los demandados: Irotama S.A.S., Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A, el Distrito de Santa Marta – la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Dirección General Marítima y Curaduría Urbana Nº 2 de Santa Marta.

Lo anterior, bajo el entendido que se había otorgado licencias de construcción y permisos en bienes de uso público, espacio público y zona de playa marítima, sin tener en cuenta el Concepto Técnico de Jurisdicción B.U.P. emitido por la Dirección General Marítima - DIMAR, a través de la expedición de las siguientes resoluciones:

- **Resolución No. 135 del 4 de mayo de 2011**, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta, mediante la cual se otorgó licencia de construcción para el Proyecto **IROTAMA RESERVADO TORRE 1.**

- **Resolución 043 de 20 de febrero de 2014**, a través de la cual la Secretaría de Planeación de Santa Marta confirió licencia de intervención y ocupación del espacio público a favor de la sociedad **GRUPO VALOR S.A.**

Argumentó el actor popular la indebida ocupación sobre playa marítima, violación al Plan de Ordenamiento Territorial – POT Santa Marta, puesto que a su juicio la construcción invade terreno de playa con características de zona de playa marítima excediéndose del límite permitido de la línea de la playa, esto es 80 metros de distancia.

Así las cosas, el accionante solicitó el amparo de los derechos consagrados en el literal d y m del artículo 4° de la Ley 472 de 1998; que se declarara la nulidad de los actos administrativos anteriormente referidos y por consiguiente se ordenara la

demolición del proyecto **IROTAMA RESERVADO TORRE 1** y la imposición de multa a la sociedad VALOR S.A. e IROTAMA S.A.S., por infracción a las normas urbanísticas y se dictara restitución del predio ocupado de hecho.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, declaró probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción, propuesta por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta, e improcedencia de este medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, por perseguir el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos y carencia total del objeto del medio de control popular en tratándose de actos administrativos propuesta por el Distrito de Santa Marta, en relación con las pretensiones de que se declaren nulas las resoluciones 135 del 4 de mayo de 2011, expedida por la Curaduría Urbana No. 2, y 043 de 20 de febrero de 2014, proferida por la Secretaría de Planeación del Distrito de Santa Marta. Así mismo, declaró no probada la excepción de pleito pendiente e irretroactividad de la Ley 472 de 1998, propuesta por la Curaduría Urbana No. 2; las excepciones de desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación de espacio público y desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de construcción, propuestas por Irotama S.A.S., también las excepciones de No corresponder los fundamentos y hechos esgrimidos en la demanda a la acción promovida, desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación de espacio público y desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de construcción propuestas por Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A., además las excepciones de inexistencia de vulneración contra el derecho colectivo al espacio público, falta de obligatoriedad de los fundamentos jurídicos y técnicos aducidos por el demandante e insuficiencia probatoria – Carga probatoria en cabeza del accionante propuestas por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta.

Por último, negó el amparo de los derechos colectivos a la utilización y defensa de los bienes de uso público y goce del espacio público y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes de Santa Marta.

Ante esto, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, reiterando lo expuesto en el escrito de contestación y alegando que no es posible que la carta catastral sea un medio de prueba idóneo para probar que el terreno donde se haya el proyecto no reviste las características de bien de uso público y que solo esta prueba es un medio de georreferenciación.

Así mismo, esgrimió que el proyecto no respetó la distancia de la playa de cara al mar caribe, es decir 80 metros de la línea de la playa, y que por mandato legal debieron observarse según el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta para la edificación de más de 15 pisos, igualmente que la Secretaría de Planeación del Distrito a la hora de expedir la licencia de intervención de espacio público en favor de la Sociedad Valor S.A., debió contar con la concepto favorable de la DIMAR – Artículo 13 del Decreto 1469 de 2010.

El Ministerio Público por su parte presentó concepto solicitando que se revocara la sentencia de primera instancia, y en su lugar conminar a la DIMAR para que dentro de un plazo razonable proceda a adoptar las decisiones de fondo en el trámite administrativo iniciado con fundamento en el concepto técnico de jurisdicción número 001-CP04-ALITMA-613 del 14 de enero de 2014, previa práctica de estudio técnico por parte del CIOH que incluya la realización de estudios de suelo, granulométricos, topográficos, botánicos, agrologicos, hidrográficos, hidrológicos y la utilización del sistema lidar, para que de esta manera se pueda determinar la presencia o no de material consolidado, la línea de vegetación permanente, el marcado cambio geomorfológico y la determinación de la menor y más alta marea en el sector, criterios relevantes para determinar si se está en presencia de playa marítima y hasta dónde llega la misma; de igual manera, que se proceda por parte de la Secretaría de Planeación Distrital a adelantar la actuación administrativa correspondiente a efectos de establecer si se ha incurrido en infracciones urbanísticas a la luz del artículo 103 de la Ley 388 de 1997, en desarrollo del proyecto IROTAMA RESERVADO TORRE I".

Respecto a lo solicitado por el Ministerio Público, resalta la Sala que en el trámite de la segunda instancia, la parte demandada puso en conocimiento del Despacho que mediante Resolución N° 0134 de 2021, emitida por la DIMAR, se ordenó el archivo de la investigación adelantada por dicha entidad en contra del GRUPO VALOR INMOBILIARIO Y OTROS, con relación la construcción indebida o no autorizadas en bienes de uso público. Situación que fue corroborada por el

apoderado de la parte demandante, quien además aclaró que apeló la decisión y a la fecha no se ha decidido el recurso interpuesto. Así mismo, la DIMAR, luego de auto de mejor proveer proferido por la Sala, se limitó a manifestar que los puntos geográficos tomados en campo coincidían con la delimitación predial de los Edificios IROTAMA RESERVADO y CONDOMINIO COSTA BELLA en la base de datos catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.

La Sala se pronunciará para resolver el recurso de alzada teniendo en cuenta lo siguiente:

El Decreto 2324 de 1984, Por el cual se organiza la Dirección General Marítima y Portuaria, en su TITULO IX. Concesiones y permisos de construcción - CAPITULO I. Generalidades, establece las definiciones de costa nacional, playa marítima y terrenos de bajamar, de la siguiente manera:

> *"Artículo 166. **Bienes de uso público**. Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren titulo alguno sobre el suelo ni subsuelo.*
>
> *Artículo 167. Definiciones. Para todos los efectos legales se entenderá por:*
>
> *1. **Costa nacional**: Una zona de dos (2) kilómetros de ancho paralela a la línea de la más alta marea.*
>
> *2. **Playa marítima**: Zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las olas de temporal.*
>
> *3. **Bajamar**: La máxima depresión de las aguas o altura mínima.*
>
> *4. **Terrenos de bajamar:** Los que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando esta baja.*
>
> *5. **Acantilado**: El área localizada en la zona de costa adyacente al mar, desprovista de vegetación y con pendientes fluctuantes entre los 45º y 90º con altura variable."*

Teniendo en cuenta la definición de playa marítima transcrita, el accionante considera que la construcción del proyecto Irotama Reservado Torre I, se construye sobre bienes de uso público, observando las características del suelo, para lo cual tiene en cuenta un concepto emitido por la DIMAR en el que se señala que dicha construcción se encuentra sobre terreno con características de playa marítima.

El mismo Decreto, en el artículo 168 dispuso que *"se reglamentará el uso y goce de todas las playas marítimas y de los terrenos de bajamar",* reglamentación que treinta y cinco (35) años después aún no se ha expedido, y que debiera empezar, como es lógico, por delimitar dichos bienes de uso público.

Teniendo en cuenta los actuales vacíos normativos sobre la delimitación del espacio público, el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 29 de abril de 2014, Rad: 11001-03-06-000-2010-00071-00, Consejero Ponente Dr. Augusto Hernández Becerra, al resolver una consulta planteada por el Ministro de Defensa Nacional y el entonces Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial respecto de la delimitación de las playas y los terrenos de bajamar, señaló que para tener certeza sobre la localización y extensión de las playas, no bastaba con las definiciones generales de la Ley, por técnicas y completas que sean, sino que dicha certidumbre deriva de que autoridades especializadas, a partir de parámetros legales y valiéndose de instrumentos y métodos científicos idóneos, efectúen la delimitación o alinderamiento de las playas y zonas de bajamar siguiendo las costas palmo a palmo, así:

> "***DELIMITACIÓN DE LAS PLAYAS Y LOS TERRENOS DE BAJAMAR***
>
> *Delimitar significa determinar y marcar los límites de un área o un espacio geográfico, ya sea en el suelo, en las aguas e, incluso, en el espacio aéreo. La noción de límite, por su parte, se refiere a la línea real o imaginaria que permite alinderar, separar o deslindar. Delimitar, por lo tanto, consiste en trazar esas líneas limítrofes con el objetivo de determinar áreas o divisiones espaciales. La delimitación del territorio tiene una gran importancia política, económica y social, pues permite fijar con precisión el ámbito espacial para el ejercicio de la autoridad y la soberanía, contribuye a establecer la titularidad y la naturaleza de los derechos que se ejercen sobre él y permite, por consiguiente, excluir pretensiones incompatibles con el régimen jurídico al que estén sometidos los respectivos bienes.*
>
> *Las playas y los terrenos de bajamar son zonas geográficas cuya ubicación y extensión dependen de distintas variables geomorfológicas, topográficas, bióticas y otras de naturaleza física, que cambian de un lugar a otro, y que incluso en el mismo sitio pueden modificarse según la época, ya sea por causas naturales o por factores de origen humano ("antrópico").*
>
> ***Resulta así evidente que para tener certeza sobre la localización y extensión de las playas en cada caso concreto no basta con las definiciones generales de la ley, por técnicas y completas que sean. La certidumbre acerca de lo que en cualquier lugar de las costas deba considerarse playa deriva de que autoridades especializadas, a partir de parámetros legales y valiéndose de instrumentos y métodos científicos idóneos, efectúen la delimitación o alinderamiento de las playas y zonas de bajamar siguiendo las costas palmo a palmo. Solo así se podrá saber con certeza en dónde se encuentran, cuáles son sus características o condiciones físicas generales, cuál es su área y cuáles sus límites exteriores e interiores.***
>
> ***El estado actual de la legislación y de la asignación de competencias a las autoridades administrativas es insuficiente para que el Estado pueda desempeñar eficiente y sistemáticamente la función de delimitar las playas. En***

> ***efecto, numerosas disposiciones legales y reglamentarias relativas a las playas y terrenos de bajamar, de manera dispersa, inconexa y a veces contradictoria, asignan funciones y competencias a distintos organismos y entidades del Estado."***

En el mismo concepto, se dejó claro que la Ley le había atribuido la competencia de delimitar las playas a varias entidades, entre las que se encuentran el INCODER, la DIMAR, los Municipios y Distritos a través de los POT y la NACIÓN, y al referirse especialmente a los Municipios y Distritos Especiales como Santa Marta indicó que en el evento de haber establecido, identificado y delimitado los "suelos de protección" en sus respectivos planes o esquemas de ordenamiento territorial**, el área de las playas y los terrenos de bajamar, tal como están definidos en el artículo 167 del Decreto-Ley 2324 de 1984, no tendría que coincidir o corresponder exacta y necesariamente con la delimitación de los referidos suelos de protección; y que en algunos casos dichos suelos pueden coincidir con las playas y las zonas de bajamar, <u>pero en otros casos los suelos de protección pueden tener un área más o menos extensa que la de las playas y los terrenos de bajamar, de acuerdo con las valoraciones urbanísticas, económicas, sociales y ambientales que haga cada municipio al momento de elaborar y aprobar su plan de ordenamiento territorial o el documento equivalente</u>,** tal como se transcribe a continuación:

> *" 2. Los municipios y distritos. Los POT*
>
> *Teniendo en cuenta que todo el espacio terrestre del país se encuentra dividido en departamentos, y estos a su vez tienen subdividido casi todo su territorio en municipios, de acuerdo con el modelo de ordenamiento territorial consagrado en nuestra Carta Política, es claro que las playas, o por lo menos las zonas interiores de las mismas (playa seca) se encuentran en la jurisdicción territorial de municipios, algunos de los cuales tienen el carácter de distritos especiales (Barranquea, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura).*
>
> *En esa medida es necesario analizar si la facultad de ordenar y regular el uso del suelo, que constitucional[33] y legalmente[34] está asignada a los municipios, les impone el deber de efectuar la delimitación de las playas marinas que se encuentren dentro de su territorio.*
>
> *El artículo 5º de la Ley 9 de 1989[35], adicionado por el artículo 117 de la Ley 388 de 1997[36], estatuye:*
>
> *"Artículo 5º... constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular; las áreas para la recreación pública... para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, <u>los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar así como de sus elementos</u> <u>vegetativos, arenas y corales</u> y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo..." (Se subraya).*
>
> *Por otro lado, el artículo 12 de la Ley 388 determina los elementos mínimos que deben incluir los municipios obligados a expedir planes de ordenamiento territorial en*

el componente general. Dentro de tales elementos se incluyen:

- *"El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales..." (numeral 2.2.);*
- *7a determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales..." (numeral 2.3);*
  7a clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano, en los términos en que estas categorías quedan definidas en el Capítulo ÍV de la presente ley." (numeral 2.5.).

El artículo 30 de la misma ley reitera que los planes de ordenamiento territorial deberán clasificar el suelo del municipio en urbano, rural y de expansión urbana, y señala que al interior de cualquiera de estos grupos podrán establecerse las categorías de suelo suburbano y de protección.

En relación con el "suelo de protección" el artículo 35 dispone:

"está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales. o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse", (se subraya).

Debe recordarse a este respecto que, según el artículo 177 del Decreto 2324 de 1984, la DIMAR no podrá conceder permisos para la construcción de vivienda en playas marítimas, prohibición que el artículo 43 de la Ley 1 de 1991[37] extendió a todas las autoridades.

A partir de las disposiciones precedentes cabría interpretar que las playas y los terrenos de bajamar deben ser considerados como "suelos de protección" y que, en la medida en que los municipios pueden identificar y deben delimitar esa categoría de suelos en sus respectivos territorios, tanto en los sectores urbanos como en los rurales y en los de expansión urbana, los municipios y distritos costeros tendrían que delimitar tales bienes de uso público en sus planes de ordenamiento territorial.

Dicha tesis, sin embargo, admite las siguientes objeciones:

i) *No todos los municipios del país están obligados a tener planes de ordenamiento territorial, con todos los componentes y requisitos que establecen los artículos 11 y siguientes de la Ley 388 de 1997. En efecto, de acuerdo con el artículo 9º, literal b) de la misma normatividad, los municipios que tengan una población de entre 30.000 y 100.000 habitantes solamente están obligados a expedir "planes básicos de ordenamiento territorial, y aquellos municipios habitados por menos de 30.000 personas únicamente están obligados a aprobar "esquemas de ordenamiento territorial, según el literal c) de la misma disposición.*

ii) Para los "planes básicos de ordenamiento territorial' y los "esquemas de ordenamiento territorial', las disposiciones pertinentes de la Ley 388 (artículos 16 y 17) no incluyen la identificación y delimitación de "suelos de protección", como una subcategoría de los suelos urbano, rural y de expansión urbana, aunque sí deben determinar las áreas o zonas de "conservación y protección de los recursos naturales y ambientales". [39]

- *De otra parte, en relación con los municipios obligados a expedir planes de ordenamiento territorial, ia ley no exige la identificación y delimitación de "suelos de protecciónEn efecto, el artículo 30 de la Ley 388, luego de señalar que los planes de ordenamiento territorial "clasificarán" el territorio municipal o distrital en suelo urbano, rural y de expansión urbana, dispone que en cada uno de estos grupos "podrán*

> *establecerse las categorías de suburbano y de protección, de conformidad con los criterios generales establecidos en los artículos siguientes" (se resalta).*
>
> *iii) Si bien está legalmente prohibido construir vivienda en las playas marítimas, la ley no proscribe de manera absoluta realizar otro tipo de construcciones, siempre que se obtengan "los permisos necesarios de las autoridades competentes". Esta es la razón por la cual, justamente, las construcciones y las ocupaciones de sectores determinados de playa requieren licencia de construcción u otro tipo de licencia urbanística, expedida por ios respectivos curadores urbanos o por las autoridades competentes de cada municipio, además de permiso, licencia o concesión otorgada por la DIMAR y licencia ambiental, tal como se explicó en el concepto N° 1682 de 2005.*
>
> • *Desde el punto de vista ambiental solo algunas playas forman parte de parques naturales nacionales o han sido calificadas como "reservas ambientales", "santuarios de fauna y flora" o "vías-parques", lo cual lleva a pensar que las playas, consideradas en sí mismas, no son una "entidad" o "unidad" conceptual que las normas ambientales reconozcan para otorgarles un tratamiento especial y diferenciado. Así mismo, no todas las playas, ni toda el área de las mismas presentan el mismo riesgo de desastres naturales para los asentamientos humanos.*
>
> ***Lo expuesto permite concluir que, aun en el caso de aquellos municipios costeros que hayan establecido, identificado y delimitado los "suelos de protección" en sus respectivos planes o esquemas de ordenamiento territorial, el área de las playas y los terrenos de bajamar, tal como están definidos en el artículo 167 del Decreto - Ley 2324 de 1984, no tendría que coincidir o corresponder exacta y necesariamente con la delimitación de los referidos suelos de protección. En algunos casos dichos suelos pueden coincidir con las playas y las zonas de bajamar, pero en otros casos los suelos de protección pueden tener un área más o menos extensa que la de las playas y los terrenos de bajamar, de acuerdo con las valoraciones urbanísticas, económicas, sociales y ambientales que haga cada municipio al momento de elaborar y aprobar su plan de ordenamiento territorial o el documento equivalente."***

Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta evidente que el Distrito de Santa Marta, a través de su Plan de Ordenamiento Territorial tiene la competencia para delimitar sus zonas de playa marítima, y en ese sentido, determinar las normas urbanísticas a seguir alrededor de dicho tipo de suelos de protección.

De lo anterior, que no resulten procedentes las sugerencias del Ministerio Público relacionadas con ordenar a la DIMAR que realice una serie de estudios de suelo, para determinar si se está en presencia de playa marítima y hasta dónde llega la misma, pues dicha información resulta irrelevante para establecer si se vulneraron normas de carácter urbanístico, porque el Distrito de Santa Marta a través de su plan de ordenamiento territorial tiene la facultad de delimitar el uso de los suelos de protección, pudiendo autorizar la construcción en algunas zonas de playa marítima.

En efecto, el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta 2000 – 2009, Jate Matuna, vigente para el momento de la expedición de las respectivas licencias de construcción, **respecto de la normativa arquitectónica y urbanística del área**

residencial Turística 3, señalada como área específica conformada por el Hotel Irotama y el proyecto de la Zona Turística de Pozos Colorados, estipuló una altura permitida de 15 pisos establecidos a 80 metros de la línea de la playa, así:

> *"2.3.1.3. Área residencial Turística 3 (Zonas Homogéneas Turísticas Especiales): **Área específica conformada por el Hotel Irotama** y el Proyecto de la Zona Turística de Pozos Colorados, adecuada para establecer patrones de baja ocupación con énfasis ambiental y densidad media. Su desarrollo debe articular las dos áreas con servicios turísticos de alto nivel y elementos de protección ambiental.*
>
> *Normativa Arquitectónica y Urbanísticas: Se establecen de acuerdo al desarrollo urbanístico sin que superen las siguientes:*
> *Área mínima de lote: 3000 m2*
> *Antejardín: 10 mtrs*
> *Retiro de fondo 1er. Piso : 10 mtrs*
> *Retiro de fondo 2do. Piso : 5 mtrs*
> *Adosamiento : No se permiten.*
> *Patio mínimo: 9 m2*
> *Retiros laterales: Acorde a la altura. (1/6)*
> ***ALTURA PERMITIDA: 15 PISOS Y SE ESTABLECEN A 80 MTRS DE LA LÍNEA DE PLAYA.***
>
> *Normativa Urbanística:*
> *Parqueaderos de vehículos para viviendas: 1 x cada viv.*
> *Parqueaderos para visitantes: 1 x cada tres viv.*
> *ÁREA DE CESIÓN: 70%*
> *VIAS VEHICULARES: Se establecen en el sistema vial. - Vías peatonales internas: 8.00 mtrs (z. Verde central)*
>
> *USOS DEL SUELO:*
> *Específico: Hotelería, Sistema de Tiempo compartido*
>
> *Complementarios: Servicios Turísticos, personales y comerciales, institucional y recreativos sobre borde de playa. Restringidos: Casinos, supermercados, marinas, Institucionales.*
>
> *Prohibidos: Industriales, Comercio Tipo 2 y 3."*

Así las cosas, para corroborar si el proyecto incumple las normativas urbanísticas, se deberá verificar con el material probatorio obrante en el expediente si dicha construcción satisface los 80 metros de línea de playa mencionados, que a juicio de la parte demandante, y de conformidad con lo señalado en la licencia de construcción (Resolución Nº 135 de 4 de mayo de 2011), el proyecto por el occidente se encuentra a una distancia de 71.40 metros con línea recta playa frente al mar caribe, desconociendo la distancia ordenada en el POT.

Una vez analizada la Resolución Nº 135 de 4 de mayo de 2011, mediante la cual la Curaduría Urbana Nº 2 otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva a la sociedad Irotama S.A., se observa que en su considerando señaló como **medidas y linderos del predio** con matricula inmobiliaria Nº 080-83688 e

inscripción catastral Nº 011000620001000, los siguientes: NORTE: 61.01 ML con terrenos cuya propiedad, posesión y/o tenencia alega Fernando Rojas, SUR: 46.64 ML con línea recta predios del Edificio Costa Bella. ORIENTE: 99.36 ML con línea recta interrumpida predio área resultante (Irotama Futuras Etapas). **OCCIDENTE: 71.40 ML con línea recta playa frente al Mar Caribe (f. 25-28).**

Cabe resaltar que en el expediente no existe ningún documento que establezca la medida exacta entre el inicio de la construcción del proyecto referenciado y el mar, y dicha información no fue posible obtenerla por el Juez de primera instancia al realizar la inspección judicial porque no contaba con los instrumentos de medición, como tampoco fue acreditada por el actor, pues este se basa en los linderos reseñados en la licencia de construcción para afirmar que se incumplen con las normas de desarrollo urbanístico. Por su parte, la DIMAR luego de requerimientos efectuados por el Despacho, se limitó a manifestar que los puntos geográficos tomados en campo coincidían con la delimitación predial de los Edificios IROTAMA RESERVADO y CONDOMINIO COSTA BELLA en la base de datos catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC. Así mismo, la parte demandada puso en conocimiento del Despacho que mediante Resolución N° 0134 de 2021, emitida por la DIMAR, se ordenó el archivo de la investigación adelantada por dicha entidad en contra del GRUPO VALOR INMOBILIARIO Y OTROS, con relación la construcción indebida o no autorizadas en bienes de uso público. Situación que fue corroborada por el apoderado de la parte demandante, quien además aclaró que apeló la decisión y a la fecha no se ha decidido el recurso interpuesto.

Ahora bien, considera la Sala necesario resaltar que resulta equivocado suponer, como pretende la parte actora que el lindero por el occidente del lote de terrero equivale a la medida de distancia que tiene el inicio del proyecto de construcción con la línea de mar, porque la medida de 71.40 metros simplemente indica el metraje desde el mar hasta que empieza el lote, que no necesariamente corresponde al lugar o línea donde se inició la construcción.

Así las cosas, no constituye la licencia de construcción prementada el medio probatorio idóneo para probar los supuestos de hecho que el accionante persigue, y este tampoco realizó ningún esfuerzo probatorio para acreditar que efectivamente se hubiesen vulnerado las normas de carácter urbanístico, incumpliendo con la carga de la prueba que le impone el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, y de allí que

se deban negar las pretensiones de la demanda relacionada con la protección de los derechos colectivos, tal como lo estimó el A-quo.

Respecto a las pretensiones relacionadas con la declaratoria de nulidad de la Resolución 135 de 4 de mayo de 2011 y Resolución 2043 de 20 de febrero de 2014, considera la Sala que el medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos no es el idóneo para desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre dichos actos administrativos. En efecto, el juez constitucional debe velar porque no se amenacen o vulneren los derechos e intereses colectivos, y en el evento de que se constate dicha vulneración podrá adoptar medidas correctivas para el cese negativo de los efectos de dichos actos, pero en ningún caso podrá anularlos; siendo competencia del medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, dependiendo de las particularidades de cada caso.

Por último, considera la Sala necesario hacer referencia a las ordenaciones proferidas por el Juez de primera instancia en la sentencia, las cuales se transcriben a continuación:

> *"**PRIMERO:** Declarar probadas las excepciones de Indebida escogencia de la acción, propuesta por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta, e improcedencia de este medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, por perseguir el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos y carencia total de objeto del medio de control popular tratándose de actos administrativos, propuesta por el Distrito de Santa Marta, en relación con las pretensiones de que se declaren nulas las Resoluciones números 135 del 4 de mayo de 2011, expedida por la Curaduría Segunda Urbana de Santa Marta, y 043 de 20 de febrero de 2014, proferida por la Secretaría de Planeación del Distrito de Santa Marta.*
>
> ***SEGUNDO:** Declarar no probada la excepción de pleito pendiente e irretroactividad de la Ley 472 de 1998, propuesta por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta.*
>
> ***TERCERO:** Declarar probadas las excepciones de Desconocimiento del actor popular respec6to a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación de espacio público, y Desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de construcción, propuestas por el apoderado de Irotama S.A.S., así como las excepciones de No corresponder los fundamentos y hechos esgrimidos en la demanda a la acción promovida, Desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de ocupación de espacio público y Desconocimiento del actor popular respecto a las disposiciones legales que autorizan la expedición de licencias de construcción, propuestas por el apoderado del Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A., y también las excepciones, de Inexistencia de vulneración contra el derecho colectivo al espacio público, Falta de obligatoriedad de los fundamentos jurídicos y técnicos aducidos por el demandante e Insuficiencia probatoria. Carga probatoria en cabeza del accionante, propuestas por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta.*
>
> ***CUARTO:** Negar el amparo de los derechos colectivos a la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce del espacio público y a la realización de*

> *las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida los habitantes de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.*
>
> ***QUINTO:*** *Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previa anotación en sistema TYBA."*

El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, Subsección B, Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth Bogotá D.C, en sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014) Radicación número: 25000-23-26-000-2001-01678-01(27507), respecto de las excepciones, manifestó:

> *"(…) las excepciones son medios de defensa dispuestos por el ordenamiento a favor de los demandados, ya que tienden, o bien a enderezar el procedimiento para evitar nulidades en el mismo, caso en el cual corresponden a impedimentos procesales que no atacan directamente a las pretensiones –excepciones previas, que se resuelven antes de continuar con el proceso-, o bien a desvirtuar las pretensiones elevadas en su contra por el demandante, en forma definitiva o temporal –excepciones de fondo o perentorias, que se deciden en la sentencia-, por lo que constituyen un verdadero ataque a la cuestión de fondo; existen también las denominadas excepciones mixtas, consistentes en hechos encaminados directamente a desvirtuar las pretensiones, es decir excepciones de fondo o perentorias, que se pueden alegar y decidir de manera previa.*
>
> *(…) Las excepciones perentorias, llamadas también de fondo y que pueden ser definitivas o temporales, están constituidas por hechos que i) desvirtúan las pretensiones, al ser demostrativos de la inexistencia del derecho alegado por el demandante, bien sea porque el mismo nunca surgió a su favor o porque habiendo existido, se extinguió; o ii) son demostrativos de que la reclamación del derecho resulta inoportuna, por estar sujeta a un plazo o condición que no se haya cumplido.*
>
> *(…) 11.* ***En el presente caso, los planteamientos que a título de excepción hizo la demandada, consistentes en la ausencia de causales que invaliden el acto administrativo demandado, constituyen apenas una negación de los hechos aducidos por la parte actora y una defensa general frente a sus pretensiones, asunto que es la materia de fondo del litigio que debe ser resuelto por el juez.***

Observa la Sala que el A-quo dispuso en la parte resolutiva de la sentencia ordenaciones referentes a declarar y no declarar probadas algunas excepciones propuestas por la parte demandada, no obstante, las mismas no constituyen excepciones sino argumentos que soportaban la defensa de las entidades demandadas y que debían analizarse por el Juez de Primera instancia con el fin de establecer la procedencia o no de las pretensiones de la demanda, como en efecto lo fueron.

En efecto, salvo la excepción de indebida escogencia de la acción y la de pleito pendiente que constituyen propiamente excepciones, los demás argumentos planteados no tienen dicha característica por ende, se deberá modificar la sentencia

de primera instancia en el sentido de declarar probada la excepción de indebida escogencia del medio de control respecto a las pretensiones tendientes a la declaratoria de nulidad de las resoluciones 135 del 4 de mayo de 2011, expedida por la Curaduría Urbana No. 2, y 043 de 20 de febrero de 2014, proferida por la Secretaría de Planeación del Distrito de Santa Marta; declarar no probada la excepción de pleito pendiente y negar las demás pretensiones de la demanda.

5.11.- Condena en costas

En virtud de lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. procede la Sala a disponer sobre la condena en costas, teniendo en cuenta las reglas previstas en el Código General del Proceso sobre la materia y el criterio objetivo - valorativo que según jurisprudencia del H. Consejo de Estado[18] rige sobre esta temática.

El numeral 1º del artículo 365 del C.G.P. señala que *"Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.* Así mismo el numeral 8º precisa *"Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación."*

Las costas están conformadas por dos rubros distintos: <u>las expensas</u>, que corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, y las <u>agencias en derecho</u>, esto es, la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora.

Por lo anteriormente expuesto, a juicio de la Sala no se encuentra acreditado en el proceso la existencia de los requisitos que se deben tener en cuenta para la condena en costas, dado que, no se evidenció conducta temeraria por las partes, que esbozaron sus argumentos con criterio jurídico razonable. Por lo tanto, atendiendo los criterios normativos y jurisprudenciales previamente expuestos, esta Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

---

[18] *Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda - Subsección A. Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Bogotá D.C., siete (7) de abril de 2016. Rad. No. 13001-23-33-000-2013-00022- 01 (1291-14). Actor: José Francisco Guerrero Bardi.*

VI. DECISIÓN

En mérito de las consideraciones expuestas, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Modificar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta el 2 de octubre de 2018, la cual quedará así:

> *"**PRIMERO:** Declarar probada la excepción de indebida escogencia de la acción, propuesta por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta, en relación con las pretensiones de que se declaren nulas las Resoluciones números 135 del 4 de mayo de 2011, expedida por la Curaduría Segunda Urbana de Santa Marta, y 043 de 20 de febrero de 2014, proferida por la Secretaría de Planeación del Distrito de Santa Marta.*
>
> ***SEGUNDO:** Declarar no probada la excepción de pleito pendiente e irretroactividad de la Ley 472 de 1998, propuesta por la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta.*
>
> ***TERCERO:** Negar el amparo de los derechos colectivos a la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce del espacio público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida los habitantes de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia."*

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, **devuélvase** el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada

MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA
Magistrada

ELSA MIREYA REYES CASTELLANOS
Magistrado

Firmado Por:

Maribel Mendoza Jimenez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Tribunal Contencioso Administrativo
Tribunal Administrativo De Santa Marta - Magdalena

Maria Victoria Quiñonez Triana
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Tribunal Contencioso Administrativo
Tribunal Administrativo De Santa Marta - Magdalena

Elsa Mireya Reyes Castellanos
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Contencioso Administrativa
Tribunal Administrativo De Santa Marta - Magdalena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5b695f9e5e500bff2c1de88b01f62c366d0334ce1276542e653f1073052600ad**
Documento generado en 19/10/2022 02:26:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica